

1502034-47.2020.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502034-47.2020.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502034-47.2020.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2125652/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 11527468 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1018/20/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2125652 - DEL.POL.SALTO, 1018/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor e Requerente:

Justiça Pública e outro

Réu:

JOAO VICTOR NUNES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra os réus ALEXANDRE CONSTANTINO e JOÃO VICTOR NUNES DA SILVA, por infração no art. 33, "caput" e 35 "caput" c. c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal no 11.343/06, cumulados com o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) e forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, em tese, em dia e local indeterminados, mas até o dia 21 de maio de 2.020, por volta das 18h33min, na Rua Monte Mor, altura do numeral 10, Jardim Marília, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, ALEXANDRE CONSTANTINO e JOAO VICTOR NUNES DA SILVA, durante período de calamidade pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, associaram-se entre si e à adolescente infratora Kemilly Lauren Rocha Gomes, com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06. Consta, ainda que no dia 21 de maio de 2.020, por volta das 18h33min, na Rua Monte

Mor, altura do nº 10, Jardim Marília, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, ALEXANDRE CONSTANTINO e JOAO VICTOR NUNES DA SILVA, agindo em concurso, previamente associados e em unidade de desígnios com a adolescente infratora Kemilly Lauren Rocha Gomes, durante período de calamidade pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, traziam consigo e tinham em depósito, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito 23 (vinte e três) porções de “cocaína”, com peso líquido de 7,88 g (sete gramas e oitenta e oito centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também que no dia 21 de maio de 2.020, por volta das 18h33min, no interior da residência localizada na Rua Penápolis, 47, bloco 6, apto. 503, Jardim Marília, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, ALEXANDRE CONSTANTINO e JOÃO VICTOR NUNES DA SILVA, agindo em concurso, previamente associados e em unidade de desígnios com a adolescente infratora Kemilly Lauren Rocha Gomes, durante período de calamidade pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, tinham em depósito, para consumo de terceiros, 14 (catorze) porções de “cocaína”, com peso líquido de 6,41g (seis gramas e quarenta e um centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 03 de agosto de 2020 (fls. 97-104).

Os réu foram notificados pessoalmente e apresentaram defesas escritas (fls.132-140 e 141-149).

A denúncia foi recebida em 03 de novembro de 2020 (fl. 157).

Durante a instrução processual foram inquiridas três testemunhas, o réu João Vistor Nunes da Silva foi interrogado e o réu Alexandre Constantino foi revel.

Em alegações finais por memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da pretensão punitiva, pleiteando pela condenação dos réus apenas pela prática do crime de tráfico de drogas.

A Defesa de Alexandre Constantino, por sua vez, requereu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e o direito de recorrer em liberdade.

A Defesa de João Victor Nunes da Silva, por seu turno, pugnou pela absolvição e, alternativamente, o afastamento da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal, da causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2.006 e o reconhecimento do redutor do artigo 33, da Lei nº 11.343/2.006, em grau máximo e, por fim, a fixação do regime aberto.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal merece parcial procedência.

Iniciando pela imputação referente à prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a materialidade e autoria delitiva ficaram comprovadas apenas com relação ao réu Alexandre Constantino, através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01-02 ), boletim de ocorrência (fls. 03-04), auto de exibição e apreensão (fl. 07), auto de constatação preliminar (fl. 08) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 249-252) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

Os policiais militares Mike Adams Carvalho e Márcio da Silva, testemunhas de acusação, relataram (transcrição em fls.264-282), em resumo, que estavam em patrulhamento e receberam denúncia de populares no sentido de que um casal estava traficando pelo local, sendo descritas as vestes do casal. No lugar indicado avistaram uma mulher agachada, próxima a um buraco na calçada e duas pessoas em pé. Após abordagem policial, a moça foi identificada como Kemilly, adolescente com 16 anos de idade, sendo que ela gozava do benefício da liberdade assistida. No local onde ela mexia foram encontradas porções de entorpecente. Os outros dois indivíduos também foram abordados, um deles identificado como Alexandre Constantino que se encontrava no mesmo local que a adolescente, com camisa de time de futebol e, ao ser revistado não trazia drogas. A adolescente Kemilly disse que a droga pertencia ao seu namorado João Vítor, apontou onde ambos residiram e disse que ele assumiria a propriedade da droga, pois ela não poderia ser presa por causa da situação que ela estava no momento. Descolaram-se até apartamento indicado pela adolescente, que forneceu as chaves, o imóvel estava revirado, localizaram mais 14

pinos plásticos transparentes na coloração azulada acondicionando cocaína, idênticos aos encontrados no cano de PVC, além da importância de R\$ 334,00 em dinheiro e cinco celulares que foram devolvidos pelo Delegado de Polícia.

A testemunha Kemilly Lauren Rocha Gomes, em juízo, relatou que tinha ido comprar um Açaí, na frente do supermercado Martins os policiais a abordaram, uma pessoa já tinha sido presa. Não levou os policiais a nenhum apartamento. Não teve nada sério com João Vítor, não morou com ele.

O réu Alexandre Constantino foi revel, vide certidão em fls. 303.

O réu João Victor Nunes da Silva, interrogado judicialmente, disse que conheceu Kemilly Lauren Rocha Gomes pela internet, ficaram duas vezes, não namoram e nem moram juntos. Não tem qualquer envolvimento com o crime.

Analisando as provas coligidas aos autos, tem-se que delito de tráfico de drogas restou demonstrado somente em relação ao acusado Alexandre Constantino.

Os policiais militares apresentaram versão detalhada demonstrando que o réu Alexandre estava na companhia de Kemilly que manuseava a droga escondida em um cano de água e, após notar a aproximação dos agentes de segurança, tentou fugir, mas foi detido, sendo que entorpecente foi localizado pelos policiais acondicionados e prontos para comercialização.

Consignaram, ainda, que o acusado Alexandre e a adolescente Kemilly são conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas, vide também certidão em fls. 238-239 e, consoante depoimento dos policiais o usuário Alan Mike F. Lecher relatou que foi ao local adquirir droga, tendo entregado dinheiro a Alexandre que repassou a Kemilly.

As declarações de policiais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, não possuem, a priori, motivo algum para falsamente incriminar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

"Os agentes públicos não se encontram impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos em que tenham atuado na fase investigatória, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando corroborados por outros elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal. A respeito ensina Guilherme de Souza Nucci: "[...]preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho." A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que "é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (...) Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ - HC: 618963 MS 2020/0269911-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 02/12/2020).

Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que as circunstâncias da prisão, a tentativa de fuga, a forma de armazenamento das drogas e a denúncia denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos depoimentos seguros das testemunhas, são suficientes a embasar o decreto condenatório. A respeito do ônus da prova por parte do acusado, esclarece Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação

do álibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o álibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

De outro lado, a prova produzida na fase inquisitiva e em Juízo não foi apta a demonstrar que João Victor Nunes da Silva exercesse o tráfico de drogas. A versão supostamente apresentada aos policiais pela adolescente Kemilly no sentido de que as drogas apreendidas em sua posse pertenciam ao seu namorado João Vítor, não foi corroborada por qualquer meio de prova. Na Delegacia de Polícia, a adolescente permaneceu em silêncio e em Juízo negou que foi com os policiais até o apartamento ou que João Victor Nunes da Silva fosse responsável pelas drogas encontradas pelos policiais.

Em relação à droga apreendida no apartamento localizado na Rua Penápolis, 47, Bloco 6, apart. 503, Jardim Marília, nota-se que nenhuma prova foi coligida aos autos apta a demonstrar que João Victor morava naquele local, nem que a droga lhe pertencia ou que estivesse em conluio com os outros réus para a prática do tráfico, pelo contrário, o réu apresentou comprovante de residência diverso às fls. 206, onde foi citado pessoalmente.

Acrescento que não foi realizado qualquer procedimento investigativo prévio. Assim, não há suporte probatório que autorize concluir que as 23 (vinte e três) porções de "cocaína" apreendidas na posse de Kemilly e Alexandre e as 14 (catorze) porções de "cocaína", encontrados no interior da residência, estivessem realmente sob a guarda do réu João Victor Nunes da Silva.

Portanto, não há provas suficientes para a condenação e deve incidir o princípio do favor rei, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, não há prova suficiente para a condenação dos acusados. A associação criminosa é um delito autônomo. Para que alguém responda por este crime são necessários os seguintes elementos: a) duas ou mais pessoas; b) acordo dos parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de traficar tóxicos.

No caso dos autos, não ficou configurado o animus associativo, o dolo, ou seja, a vontade de se associar. A denúncia não narrou o modo nem o momento em que teria se estabelecido o vínculo associativo entre os acusados. Além disso, reitero que não houve a realização de qualquer procedimento investigativo prévio, nem prova sob a égide do contraditório, que demonstrasse um mínimo de organização e planejamento para a prática da associação criminosa. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, relembro que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição pela prática do delito de associação para o tráfico, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, o caso é de mero concurso de pessoas. 3. As instâncias ordinárias embasaram a condenação dos pacientes em elementos fáticos e probatórios concretos - com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais -, os quais, detidamente examinados em primeiro e segundo graus de jurisdição, conduziram à conclusão de que os réus integrariam, de maneira estável e permanente, associação criminosa voltada à

comercialização ilícita de entorpecentes. Assim, desconstituir tal entendimento, para absolver os pacientes, implicaria aprofundado reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso dos autos, não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois a referida benesse não é aplicável a réus também condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, circunstância que denota, necessariamente, a sua dedicação à atividade criminosa. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 618503 RJ 2020/0267075-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 14/12/2020)",

Assim, a absolvição dos réus Alexandre Constantino e João Victor Nunes da Silva pelo crime de associação ao tráfico é medida que se impõe. No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O contexto de calamidade pública, ainda que decretado pelo Poder Público, não é apto à caracterização da agravante, no caso presente, a não ser que, v. g., se estivesse em cenário particularizado, como a falsificação de uma vacina ou o descumprimento de medida sanitária preventiva." (Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047, Relato: Guilherme de Souza Nucci.).

Para fins de dosimetria da pena, resalto que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para valorar a pena base. O Plenário do STF, em julgamento de repercussão geral, firmou o entendimento de que: "PENAL- FIXAÇÃO - ANTECEDENTES CRIMINAIS - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais". (STF RE 591054). O mesmo posicionamento foi cristalizado pelo Enunciado nº 444 da Súmula do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base".

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para a utilização na diminuição da pena.

O legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. É lógico que há de existir o cuidado de evitar "bis in idem". Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 7,88 g (sete gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína, as ações penais em curso não são considerados como maus antecedentes ou reincidência, o réu é tecnicamente primário (fls. 238-239) e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de policiais

militares sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Salientando-se que inquéritos e ações penais em curso não impedem a aplicação do mencionado redutor. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 56,8g de maconha, 32,6g de cocaína e de 8,6g de cocaína na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial somada à prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Condenação mantida. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima. Admissibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Ausência de prova da dedicação a atividades criminosas. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade e das circunstâncias judiciais favoráveis. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 1500316-10.2020.8.26.0366; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

APELAÇÃO (recurso apenas defensivo) – Tráfico de entorpecente – Pleito da Justiça Gratuita atendido. "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça" (§ 4º do art. 99 do NCPC), anotando-se, porém, na esteira do sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que "A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos" e que "a análise da miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções", até porque pode sobrevir, naquele lustro, "mudança na situação econômica da beneficiária" – No mais, materialidade e autoria delitivas comprovadas – Sem olvido de que "Toda pessoa poderá ser testemunha" (art. 202 do CPP) – , nada foi comprovado em pretório (art. 156 do CPP) que demonstrasse qualquer equívoco, animosidade ou inimizade a retirar a credibilidade da prova testemunhal policial, não se podendo inferir, pois, que houvesse na espécie incriminação sem justo motivo. Seria um contrassenso a sociedade organizada (Estado) arregimentar pessoas para a atividade policial e depois negar-lhes valia no trabalho realizado. Ademais, existe, in casu, testemunha civil também a incriminar a ré – Em casos dessa ordem, onde a traficância imputada não é na modalidade "vender", em nada beneficia a acusada o fato de ela não ter sido avistada contatando outras pessoas e/ou vendendo-lhes o estupefaciente, nem mesmo a circunstância de nenhum tóxico ter sido encontrado em seu poder no momento da abordagem policial, eis que a increpação é de que ela "guardava" e "tinha em depósito" a droga, afigurando-se desnecessário saber, inclusive, de quem era a propriedade respectiva, posto que, onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo – Comprovada a narcotraficância irrogada, impossível a desclassificação para a infração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – Tráfico Privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006). Cabimento. Como processos e/ou inquéritos em curso não podem ser considerados na fixação da pena-base, em face do princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art.5º, LVII), pela mesma razão também não se afiguram aptos a obstaculizar, ainda no momento dosimétrico (terceira etapa), a figura privilegiada (onde existe a mesma razão, aí há o mesmo direito: ubi eadem ratio ibi idem ius). (STF e STJ) – Indemonstradas circunstâncias outras a obstar a benesse legal, a aplicação de tal redutor legislado deve se dar no máximo legal (2/3), dado que o tóxico apreendido o foi em pequena quantidade (menos de 4 gramas de crack), com regime inicial aberto (diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, da primariedade e do quantitativo sancionatório), como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime no caso concreto (CP, art. 33, §2º, "c", e §3º, c.c. o art. 59, caput, in fine, e III, e com o artigo 42 da Lei de Drogas) – Inconstitucionalidade do valor da pena de multa prevista na Lei Antidrogas – Inocorrência. A Lei nº 11.343/2006 é especial em relação ao Estatuto Repressivo (art. 49), de modo que,

com rigores sancionatórios insitos à inafastável necessidade de se tutelar a saúde pública, deve prevalecer sobre a regra geral (*lex specialis derogat legi generali*), sem qualquer inconstitucionalidade, até porque editada pelo Poder Legislativo, a quem cabe, na sua tarefa de satisfação do interesse público, não só definir os tipos penais, mas também estabelecer as respectivas sanções. Toda e qualquer punição estatal advinda de condenação criminal repercute, de uma maneira ou de outra, no *ius ambulandi* do sentenciado, com inegável reverberação econômica não só à sua pessoa, como também àquelas que dele monetariamente dependam. Mas isso não pode significar, por óbvio, violação à intranscendência subjetiva das sanções, albergada no artigo 5º, XLV, da Constituição da República; as normas constitucionais não comportam interpretações estanques, devendo coexistir contextualmente, e, assim, também permitir a apenação daqueles que infringirem a normatividade penal posta, como se depreende de vários dos incisos hospedados naquele mesmo artigo 5º. Tem-se, nesse contexto, a busca do primado maior da Justiça, de se dar a cada um o que é seu (*suum cuique tribuere*), inclusive individualizando-se a pena, como expressamente contemplado no citado artigo 5º, desta feita no inciso XLVI, e dessa forma possibilitar o respeito à harmonia e ao bem-estar sociais, consoante o preâmbulo da mesma Lei das Leis – Presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena corporal por duas restritiva de direitos, a teor da segunda parte do § 2º (quantum superior a 1 ano) do artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. Inviável tal permuta "por multa"; diversamente, se estaria desnaturando a mens legis, que cominou à espécie, cumulativamente, reprimenda prisional e (também) multa, de maneira que a aplicação de uma nova pena de multa não se afigura socialmente recomendável em casos que tais, pois, em última análise, ter-se-ia como resultado somente sanção pecuniária (STJ) – DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1501447-21.2019.8.26.0571; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021). Fixadas tais premissas, passo a dosar a pena, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

ALEXANDRE CONSTANTINO

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é tecnicamente primário (Súmula 444 STJ), culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, presente a atenuante da menoridade, porém, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Presente a causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da lei nº 11.343/2006, pois o tráfico envolveu o adolescente Kemilly Lauren Rocha Gomes, nos termos acima delineados, aumento sua pena de um sexto, atingindo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

- 1) CONDENAR o réu ALEXANDRE CONSTANTINO à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10

(dez) dias e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

2) ABSOLVER o réu ALEXANDRE CONSTANTINO da prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

3) ABSOLVER o corréu JOÃO VICTOR NUNES DA SILVA da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando que o réu Alexandre Constantino respondeu ao processo em liberdade e, não havendo motivos para decretação da custódia cautelar, concedo o direito de apelar sem recolher-se à prisão, se por outro processo não estiver preso.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP à advogada dativa, para retirada exclusivamente pela internet.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA